

刑 法
No159

共通問題 H27-15

(配点: 3)

月 日

月 日

結果的加重犯の共同正犯の成立が認められることを前提に、次の【事例】及び各【見解】に関する後記1から5までの各【記述】を検討し、誤っているものを2個選びなさい。

【事例】

甲と乙は、丙に対する傷害を共謀し、共同して木刀で丙の手足を殴打していた際、甲は丙に対する殺意を抱き、木刀で丙の頭部を殴打し、丙はその殴打により脳挫傷で死亡した。なお、乙は、甲が殺意を抱いたことを知らなかった。

【見 解】

A説：共同正犯とは、数人が犯罪に至る行為過程を含めた行為を共同することであり、特定の犯罪を共同して実現する場合はもちろんのこと、単なる行為を共同して各自の意図する犯罪を実現する場合も、それぞれの行為について共同正犯の成立を認める。

B説：共同正犯とは、数人の者が共同して特定の犯罪を行うことであり、構成要件の間に重なり合いがあれば、そのうちのより重い犯罪について共同正犯の成立を認め、軽い犯罪の故意しかない者には、軽い犯罪の刑を科す。

C説：共同正犯とは、数人の者が共同して特定の犯罪を行うことであり、構成要件の重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認める。

【記 述】

1. A説からは、甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。
2. B説からは、甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。
3. B説に対しては、犯罪の成立と科刑が分離するのは妥当でないと批判できる。
4. C説からは、甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し、甲には殺人罪の単独犯が成立するとの結論が導かれる。
5. C説に対しては、A説やB説から、共同正犯の成立範囲が広すぎると批判できる。

【見解について】

見解Aは、単なる行為を共同して各自の意図する犯罪を実現する場合も、それぞれの行為について共同正犯の成立を認める立場であるから、行為共同説からの説明である。見解Bは、数人が特定の犯罪を行うことが必要であり、構成要件の重なり合いがあれば共同正犯の成立を認める立場であるから、部分的犯罪共同説に立つことが分かる。その中でも、重い犯罪について共同正犯の成立を認め、軽い犯罪の故意しかない者には、軽い犯罪の刑を科す立場であるから、いわゆるかたい部分的犯罪共同説からの説明である。見解Cは、数人が特定の犯罪を行うことが必要であり、構成要件の重なり合いがあれば共同正犯の成立を認める立場であるから、部分的犯罪共同説に立つことが分かる。その中でも、構成要件の重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認める立場であるから、いわゆるやわらかい部分的犯罪共同説からの説明である。

【記述について】

1 誤っている

A説は、各人が行為を共同することによって各人の犯罪を実現するものとする立場であるから、共同者の故意に対応して、異なった犯罪間においても共同正犯が成立する。本問において、甲は丙に対し殺意を抱き、木刀で丙の頭部を殴打し、その殴打による脳挫傷が原因で丙を死亡させているから、殺人罪の共同正犯が成立する。一方、乙は、甲の殺意を知らず、傷害の故意で丙の手足を木刀で殴打しているから、傷害致死罪の共同正犯しか成立しない。よって、甲には殺人罪の共同正犯が、乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。したがって、A説からは、甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論は導かれないため、記述1は誤っている。

2 正しい

B説は、構成要件に重なり合いがあれば、そのうち重い犯罪について共同正犯の成立を認め、軽い犯罪の故意しかない者には、軽い犯罪の刑を科す立場である。本問において、甲の行為は殺人罪の、乙の行為は傷害罪の構成要件に該当し、両者は傷害致死罪の範囲で重なり合いが認められる。よって、甲と乙には殺人罪の共同正犯が成立し、軽い傷害の故意しかない乙には傷害致死罪の刑が科される。したがって、B説からは、甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれるため、記述2は正しい。

3 正しい

B説の立場では、軽い犯罪の故意しかない者には、重い犯罪が成立するが、軽い犯罪の限度で処断されることになる。本問においては、記述2でみたように、乙には殺人罪の共同正犯が成立するが、傷害致死罪の刑の限度で処断されることになる。かかる見解に対しては、犯罪の成立と科刑が分離するのは妥当でないとの批判が可能である。したがって、B説に対しては、犯罪の成立と科刑が分離するのは妥当でないとの批判が可能であるため、記述3は正しい。

4 正しい

C説では、構成要件の重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認める。本問においては、殺人罪と傷害致死罪の重なり合う軽い傷害致死罪の限度で共同正犯が成立することになる。よって、甲と乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。また、殺意のあった甲には、殺人罪の単独犯も成立する。したがって、C説からは、甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し、甲には殺人罪の単独犯

が成立するとの結論が導かれるから、記述4は正しい。

5 誤っている

C説では、本問の甲と乙に、傷害致死罪の範囲でしか共同正犯の成立を認めない(記述4参照)。一方、B説では、甲と乙に殺人罪の共同正犯の成立を認める(記述2・3参照)。よって、C説は、B説より共同正犯の成立範囲が狭いといえる。したがって、C説に対しては、少なくともB説から、共同正犯の成立範囲が広すぎると批判することはできないため、記述5は誤っている。